

1500054-49.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... local conhecido por ter alto índice de tráfico de drogas, com um certo volume na cintura. Ao ser abordado os milicianos encontraram em poder do réu um estojo de óculos contendo em seu interior 40 pedras de crack e 12 pinos de cocaína prontos para a comercialização, bem a quantia de R\$ 47,55 em dinheiro trocado, certamente proveniente do narcotráfico.

Indagado informalmente pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500054-49.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-49.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2007286/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 15578655 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 78/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2007286/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Jacareí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO AUGUSTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. JOÃO PAULO AUGUSTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Jose Fama de A. Viana, 39, Jardim Conquista, nesta cidade e comarca, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de

tráfico, as seguintes drogas: 40 pedras de crack; 12 pinos de cocaína e 52 invólucros de maconha.

A denúncia foi oferecida em 1º de fevereiro de 2021 (fls. 86/88).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 119/122).

Posteriormente, a denúncia foi recebida por decisão em 16 de abril de 2021 (fls. 131/134).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi localizado para intimação pessoal, sendo decretada a sua revelia.

Em alegações finais, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia.

A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu. Em caráter subsidiário postulou a desclassificação da imputação inicial para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. No caso de condenação a pena deverá ser estabelecida no patamar mínimo, aplicando-se a causa de redução da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo, a qual deverá ser substituída nos termos do artigo 44, do Código Penal, estabelecendo, ainda, o regime inicial aberto, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/14), Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), Laudo de Constatação Prévia de substâncias entorpecentes (fls. 23/25), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 79/81, que constatou tratar-se, efetivamente, de substância entorpecentes.

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu JOÃO PAULO AUGUSTO negou o crime ao ser interrogado durante a fase extrajudicial, aduzindo ser apenas usuário de drogas e estava na posse de apenas duas pedras, desconhecendo a procedência das drogas apreendidas. Em juízo, o réu tornou-se revel, pois não foi encontrado para intimação pessoal no endereço por ele fornecido no curso da ação penal.

A testemunha RODRIGO APARECIDO NUNES DE MORAIS, Policial Militar, declarou que realizavam patrulhamento ostensivo pelo local, onde há grande incidência de tráfico de entorpecentes nesta cidade, quando notaram um indivíduo que seguia pela via pública com um volume na altura da cintura, o qual foi abordado. Durante a busca pessoal encontraram com o referido indivíduo um estojo de óculos contendo em seu interior 40 pedras de "crack" e 12 pinos de cocaína prontos para comercialização, além da quantia de R\$ 47,55 entre cédulas e moedas. Indagado informalmente o acusado admitiu eu estava comercializando substâncias entorpecentes para o seu sustento, indicando nas proximidades, entre a guia e um veículo, outro estojo contendo 52 pequenas porções de maconha. O réu recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO, que participou da prisão do acusado em conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade.

O réu estava parado defronte ao portão e quando viu a viatura tentou sair caminhando. O réu admitiu informalmente a prática delitiva.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes no sentido de que o réu efetivamente trazia consigo e guardava diversas substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência foram coerentes e harmônicos entre si quando da descrição de toda a dinâmica da ocorrência. O réu foi avistado em atitude suspeita caminhando pela via pública descrita na denúncia, local conhecido por ter alto índice de tráfico de drogas, com um certo volume na cintura. Ao ser abordado os milicianos encontraram em poder do réu um estojo de óculos contendo em seu interior 40 pedras de crack e 12 pinos de cocaína prontos para a comercialização, bem a quantia de R\$ 47,55 em dinheiro trocado, certamente proveniente do narcotráfico.

Indagado informalmente pelos policiais o acusado João Paulo afirmou que realmente estava comercializando os entorpecentes para o seu sustento, e indicou um local, bem próximo, entre a guia e um veículo, onde ocultava outro estojo de óculos contendo 52 invólucros de maconha também prontos para distribuição.

Anoto, nesta oportunidade, que a versão extrajudicial apresentada pelo increpado, que tornou-se revel em juízo, não veio corroborada por qualquer elemento de convicção. Afinal, segundo relato dos milicianos, o réu não aparentava estar sob efeito de drogas e não trazia consigo qualquer objeto intimamente ligado ao consumo das substâncias entorpecentes variadas que trazia consigo (maconha e cocaína). Soma-se a isso a quantidade e variedade de drogas apreendidas, dinheiro trocado encontrado com o réu, e a sua própria confissão informal.

Por outro lado, os Policiais Militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar o réu.

Nesse sentido: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (TJSP – AP – 1ª C. – Rel. Marcial Holanda – j. 10.04.95 – RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

Assim, as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado não deixam nenhuma dúvida acerca da atividade ilícita por ele desenvolvida, prejudicando, neste passo, o pleito da Douta Defesa para desclassificação da conduta inicial para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.

A condenação do réu é de rigor, nos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma preconizada pelo artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem analisadas.

No tocante à agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal, este Magistrado vem reiteradamente afastando a sua incidência em casos semelhantes.

De fato, esta circunstância agravante não pode ser analisada de forma objetiva por si só e aplicada indistintamente para todos os crimes praticados durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Dessa forma, o crime praticado pelo acusado deve ser verificado de acordo com o contexto fático, ou seja, o agente criminoso deve, de alguma forma, ter se aproveitado da situação calamitosa para a prática da infração penal.

E não vislumbro nos autos qualquer indicativo de que o réu tenha se beneficiado de alguma forma do estado de calamidade pública para a prática do ato criminoso em testilha.

Nesse sentido, cabe trazer à baila ensinamento doutrinário proferido por Cleber Masson: "Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhas postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime" (Masson, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. 13ª, São Paulo: Método, pág. 581).

No caso em tela, o delito poderia ter sido praticado, indiferentemente, em momento sem a calamidade pública decretada pelo Poder Público.

Na terceira fase da aplicação da pena, considerando, de um lado, que o réu é primário, jovem, não havendo prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, e de outro, a elevada quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (40 pedras de crack, 12 pinos de cocaína e 52 invólucros de maconha - 104 porções no total), aplico a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2005, reduzindo a pena base fixada em 1/2, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 dias-multa.

Especificamente sobre o benefício acima referido este Magistrado adota o entendimento no sentido de que a redução da pena deve ficar ao arbítrio do Juiz, que deverá levar em consideração o artigo 59, do Código Penal e, também, o artigo 42, da Lei 11343/06. Evidentemente que a redução no patamar máximo não é obrigatória pela própria redação do dispositivo legal em testilha (artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 - "As penas poderão ser reduzidas..."), principalmente por não se tratar de direito subjetivo do réu. Nesse sentido, aliás, decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou justa a redução intermediária, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 para caso semelhante: "... Artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Redução Máxima. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida (36 porções contendo cocaína). Concessão do benefício depende do livre arbítrio do Juiz que tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42, da Lei 11343/06. Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 990.10.175503-3, Itaquaquecetuba, 6ª Câmara de Direito Criminal,

Relator Desembargador Machado de Andrade, j. 26 de Agosto de 2010).

No caso concreto, nos termos acima delineados, o acusado foi surpreendido traficando drogas, trazendo consigo 104 porções de substâncias ilícitas variadas (cocaína, crack e maconha) prontas para entrega a consumo de terceiros. Mas, por outro lado, ele é jovem, primário, motivo pelo qual entende este Magistrado que está justificada a redução da pena no patamar intermediário estabelecido, tomando-se por base o artigo 59, do Código Penal e o artigo 42, da Lei 11343/06.

E o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão es em caso semelhante a este tratado nestes autos. Confira-se a propósito: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor no percentual de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a considerável quantidade de substância entorpecente - 103 gramas de cocaína, 37 gramas de crack e 560 gramas de maconha - apreendida com o paciente. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA CORTE ORIGINÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 617 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Constatado que o Tribunal, julgando apelo exclusivo da defesa, findou por não aplicar a causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, expressamente reconhecida na sentença em favor do paciente, resta evidenciada a reforma a pior nesse ponto, em nítida ofensa ao art. 617 do CPP, que proíbe a reformatio in pejus, constrangimento sanável de ofício através da via eleita. REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07. MODO FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1. A Lei 11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, estabeleceu o regime inicial fechado para o resgate da reprimenda firmada em relação aos delitos hediondos, cometidos após a sua entrada em vigor. 2. Ordem denegada, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício para fixar a pena do paciente definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa" (STJ, HC 202758 / SP, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 07.02.2012).

Não há causas de aumento de pena.

Finalizando, no caso concreto, tendo em vista as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da lei de drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, que é jovem, não ostenta qualquer passagem criminal, e ao que tudo indica agiu como mero traficante eventual.

Portanto, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, a ser estabelecida

pelo juízo da execução penal, e outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia de 01 salário mínimo, que será revertido para instituições carentes devidamente cadastradas por este juízo.

No caso de descumprimento do benefício o réu irá cumprir a pena em regime inicial aberto, compatível com a pena aplicada ao réu, atentando, ainda, para recente entendimento do Supremo Tribunal Federal afastando a natureza hedionda do tráfico privilegiado e para o período de duração da prisão cautelar.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu JOÃO PAULO AUGUSTO a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do Código Penal, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se o necessário para início da fase executória.

Jacarei, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA